

1502908-83.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... havia movimentação típica de tráfico de drogas, sobretudo diante da detenção João Vitor no mesmo local, integrante do casal mencionado que teria vindo de Guataparã já conhecido pela venda de drogas e que, também neste outro ambiente, estariam a proceder do mesmo modo.

Everaldo assinalou servir o imóvel ao recrutamento de agentes do tráfico e, para que não se diga ser essa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502908-83.2021.8.26.0530 - controle nº 2022/000012

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2346224/2021 - DEL.POL.GUATAPARÁ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jessé Ferreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

JESSE FERREIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia, horário e local descritos na denúncia foi surpreendido trazendo consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fim de entrega a terceira pessoa, droga, consistente em 2,48 gramas de cocaína, em 8 invólucros de plástico de cor branca, e 0,85 gramas de cocaína (na forma de crack), em 4 invólucros de plástico incolor vedados por nó. Narra a denúncia que policiais militares, após receberem informação de que a residência do acusado (local dos fatos) estava sendo utilizada para a prática de traficância, ao visualizarem duas pessoas em atividade suspeita, foram em sua direção, ocasião em que uma delas conseguiu fugir e a outra (o acusado) adentrou à morada.

Em seguida, diante da situação de flagrância então existente, os referidos agentes adentraram em seu interior, ocasião em que abordaram o acusado e, em seu poder, encontraram as drogas acima descritas, bem como a quantia de R\$ 10,00, cuja origem

não foi declinada.

Dispensada a audiência de custódia, na forma do Provimento CSM 2633/2021, bem como Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em razão do risco de contaminação pelo COVID-19, o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 21 de dezembro de 2021 (págs. 94/96).

Pessoalmente notificado (pág. 142), o acusado apresentou defesa preliminar (págs. 146/152) e a denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 27 de janeiro de 2022 (págs. 153/154), sendo o acusado, na sequência, citado (pág. 162). Designada audiência de instrução, debates e julgamento, com a ferramenta Microsoft Teams a prova oral foi colhida e interrogado o acusado. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia e deixou de insistir na imposição de indenização por dano moral coletivo por ser o acusado hipossuficiente e consistirá em medida inócua do ponto de vista social. A Defesa refletiu ser pouca a quantidade de entorpecentes apreendidos, assim como o dinheiro, tudo compatível à condição de usuário e de dependência química do acusado; debateu que até mesmo o policial Everaldo, em seu testemunho, na abordagem anterior aos fatos, não demonstrava crer no exercício da traficância pelo acusado, ao orientá-lo deixar a região dos fatos; diante disso, requereu a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06; afirmou fragilidade probatória, pois os fatos não são antigos e não haveria justificativa ao esquecimento pelos policiais das circunstâncias do episódio; subsidiariamente, ponderou não ser o acusado reincidente específico, a viabilizar o reconhecimento do redutor do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 e a imposição de regime prisional diverso do fechado para início de cumprimento de pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 18/20 e no exame químico-toxicológico acostado a págs. 118/120 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) alcaloide extraído do vegetal "Erythroxylum coca", num total de 2,48 gramas, acondicionado em 08 invólucros plásticos, bem como, da mesma substância, 0,85 gramas, acondicionado em 04 invólucros plásticos incolor vedados por nó, além de R\$ 10,00, conforme depósito de pag. 117 e auto de exibição e apreensão de pag. 10.

Igualmente demonstrada a autoria.

Everaldo Saraiva, policial militar, recordou que a linha férrea, região dos fatos, é conhecida pela prática de tráfico de drogas e o acusado foi visto, no período da manhã, na companhia de casal já envolvido na venda de drogas; descreveu que a abordagem ocorreu próximo da linha férrea em uma casa de portão verde; detalhou que as pessoas reunidas fugiram, ao passo que o acusado correu tentando entrar na casa (informou que traficante de Ribeirão Preto, recentemente preso, recrutava pessoas para traficarem no local), mas logo no portão sofreu a abordagem que, na busca pessoal, resultou na apreensão das drogas no bolso da bermuda vestida pelo acusado, além de dez reais em dinheiro; indagado informalmente, continuou, o acusado haveria dito estar em situação de rua e precisava "levantar dinheiro" com a venda das drogas com ele encontradas, pois a família não o aceita mais em Pradópolis.

Bruno Campos Alves, também policial militar, não se recordou de detalhes quando inquirido na fase judicial, mas ratificou o depoimento prestado em fase extrajudicial, no mesmo sentido das informações prestadas por seu companheiro de corporação acima inquirido.

Interrogado, o acusado negou os fatos a ele imputados, pois alegou que uma semana antes, no período da manhã, os policiais, sem mandado judicial, ingressaram pelo portão da casa, em cujo interior se encontrava na companhia de uma casal de amigos (um deles chamado João Vitor, preso recentemente por tráfico) e haveria sido alertado para deixar a cidade até às 17h, pois, do contrário, "iriam arrumar alguma coisa" em seu desfavor; disse ter permanecido na cidade e, uma semana depois, nas mesmas condições da abordagem anterior (pelo portão e sem mandado), desta vez sozinho, houve o encontro em sua posse (debaixo de seu travesseiro) de doze porções

de “pedra” (cocaína na forma de crack), inexistindo cocaína em pó, tampouco a quantia de dez reais em dinheiro (o único dinheiro que possuía – recebido de doações “banguendo na rua” – gastou na noite anterior na compra de um maço de cigarro e um BIC para fazer “cinza”).

Negou, portanto, estar fora da casa traficando ou ter saído correndo, na forma colocada pelos policiais, e sim que se encontrava dormindo, após ter consumido três “papéis” de pedra das quinze que havia adquirido; declarou ser dependente químico há aproximadamente sete anos, um mês antes esteve na comunidade terapêutica de Jardinópolis chamada “Caminho da Paz”, além de já ter passado por Santa Rita e outras congêneres, no total de cinco internações; afirmou que usava a casa (estava há uma semana em Guatapará) por liberalidade de um amigo, era assistido por também alguns outros amigos no que diz respeito à alimentação, e confirmou que a região é conhecida pelo tráfico de drogas.

O conjunto probatório produzido nos autos conduz à conclusão de que o acusado incidiu na prática delituosa narrada na denúncia.

Ao que se verifica da prova oral produzida, incontroverso que o acusado mantinha com ele a droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com destinação a terceira pessoa.

Em retomada ao já antes manifestado em fase extrajudicial (pág. 3), o policial Everaldo expôs que, de notícias prévias envolvendo não só a região da linha férrea ou o bairro, como também a casa onde o acusado permanecia, havia movimentação típica de tráfico de drogas, sobretudo diante da detenção João Vitor no mesmo local, integrante do casal mencionado que teria vindo de Guatapará já conhecido pela venda de drogas e que, também neste outro ambiente, estariam a proceder do mesmo modo.

Everaldo assinalou servir o imóvel ao recrutamento de agentes do tráfico e, para que não se diga ser essa uma observação genérica, bem frisou ter o acusado mencionado que, por força de estar em situação de rua, precisava “levantar dinheiro” com a droga, pois seus familiares não o aceitavam de volta em Pradópolis. Isso reforça o conjunto de depoimentos outrora prestados na fase extrajudicial, nos quais feitas prontas referências ao fato de que, a surgir a equipe policial, as pessoas, bem na região da linha férrea (onde o próprio acusado confirmou ser ponto de tráfico) empreenderam fuga e o acusado, bem no limiar do portão da casa, veio a ser detido e com ele apreendidas as porções de entorpecente.

Detalhes esquecidos ou confundidos que não atingem a essência do depoimento em si não comprometem a prova produzida, na medida em que os “pequenos esquecimentos nos testemunhos não têm o condão de comprometer todo o acervo probatório. O importante é que os depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes detalhes olvidados ou confundidos, considerando-se que a mente humana não é perfeita. No que interessa, as narrativas dos agentes públicos não deixam dúvidas quanto ao ocorrido” (TJSP; Apelação Criminal 0013940-46.2011.8.26.0196; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/07/2013; Data de Registro: 05/07/2013).

Ainda nesse sentido:

[...] Pequenos esquecimentos ou contradições que não se mostraram essenciais para o reconhecimento do crime, justificado ainda pelo grande número de ocorrências que atendem por mês. [...]

(TJSP; Apelação Criminal 0058217-22.2013.8.26.0506; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/04/2016; Data de Registro: 26/04/2016)

No essencial, muito embora o policial Bruno não tenha se lembrado pontual e especificamente sobre cada tipo de detalhe, o testemunho de Everaldo atinge o que é essencial e se coaduna com o conteúdo já manifestado em fase anterior, não prejudicando a clareza na elucidação do ocorrido, conforme relevante trecho de aresto emanado deste tribunal de justiça paulista: [...] Depoimentos dos policiais coerentes e seguros quanto aos aspectos nevrálgicos da dinâmica delitiva, não havendo qualquer indício de intenção de prejudicar o réu injustamente. Pequenos esquecimentos nos depoimentos, irrelevantes e que não turvam a clareza da prova

[...]” (TJSP; Apelação Criminal 0013940-46.2011.8.26.0196; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/07/2013; Data de Registro: 05/07/2013).

Inversamente, o acusado sustentou ter sofrido agressões e outros agravos de violação legal em sua residência; entretanto, no laudo médico de págs. 16/17 há o registro de que “se encontra assintomático, sem quaisquer queixas” e tampouco houve narrativa desabonadora à ação policial na ocasião de seu interrogatório (pág. 4), ato ao qual disse não ter se submetido, sequer falado com a autoridade policial, só que, contraditoriamente, há informações que só poderiam ser sabidas mediante entrevista pessoal com o próprio acusado tais quais, dentre outras, de ter um filho com dezoito anos de idade, endereço de residência, ser solteiro e fazer uso de cocaína e crack.

Para a consumação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiros pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

“Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas” (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792) ; “No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de “trazer consigo” e “guardar”, não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda.” (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844); “Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela quantidade, variedade, natureza e forma de acondicionamento, divididos em porções individuais, pela detalhada informação apócrifa, cuja veracidade foi constatada pelos agentes públicos, elementos suficientes à procedência da pretensão punitiva, não remanescendo quaisquer dúvidas, quanto ao destino a terceiros, salientando-se que eventual condição de usuária não seria impeditiva da realização concomitante do comércio clandestino, o que arreda a tese desclassificatória ventilada em autodefesa.” (TJ-SP; APL 0001364-89.2016.8.26.0537; Ac. 10947155; São Bernardo do Campo; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Eduardo Abdalla; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2794).

A hipótese não é a de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, pois ficou evidente que o entorpecente que o acusado tinha em sua posse destinava-se ao fornecimento a terceiros e não meramente ao consumo pessoal, eis que reunia consigo quantidades fracionadas, dois tipos de drogas (na forma de pó e de pedra), além da apreensão conjunta de dinheiro, tudo convergindo para corroborar o exercício, sim, da traficância.

Embora possa ser dependente de drogas o acusado, “eventual condição de dependente não afasta a responsabilidade pelo tráfico, porque perfeitamente natural a coexistência entre o cidadão dependente e o mesmo cidadão traficante”

(TJSP; Apelação Criminal 0013940-46.2011.8.26.0196; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/07/2013; Data de Registro: 05/07/2013).

O requerimento ministerial postulado na denúncia, no item “c” de pág. 128, de fixação de valor mínimo a título de reparação por dano moral coletivo, não comporta acolhimento, seja diante da particularidade de o tráfico de drogas ser definido como de perigo abstrato, sem vítima determinada, crime vago, que ofende toda a coletividade, cujo dimensionamento do dano estaria submetido a complexidade que, a não ser por presunção ou amostragem, encontraria obstáculos quanto à suficiente aferição do real prejuízo suportado pelo meio social, seja, de outro lado, em razão de o legislador, ao atender o comando constitucional instituído no inciso XLIII, do artigo 5º, da Constituição Federal/88, estabeleceu, à rigidez exigida à conduta, multa variável de 500 a 1500 dias-multa, suplantando a regra geral de 10 dias-multa, prevista no artigo 49, do Código Penal, a revelar que a densidade do apenamento ao tráfico, sobretudo na quantificação da multa, já segue parâmetros que tomam em consideração a reversão do dano, do ponto de vista pecuniário, que a conduta provoca.

Nestes termos, confira-se substancial trecho extraído do voto condutor de acórdão prolatado no âmbito do Tribunal de Justiça paulista:

“levando em consideração que o Ministério Público cuidou em suas razões da questão da indenização a título de dano moral coletivo, cumpre observar que muito se reconhece acerca da evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico, o que evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima de infração penal, contemplando, entre outros instrumentos, a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano, o material e o moral, desde que a providência tenha sido reclamada expressamente pelo Ministério Público na denúncia.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem afirmado a possibilidade de fixação, pelo Juízo Criminal, de um valor mínimo a título de indenização por danos morais, considerando que a norma não limitou ou tampouco regulamentou como será quantificado o valor mínimo indenizatório.

E tomando por pressuposto de que a legislação penal priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o Magistrado que se sentir apto, diante do caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, na dicção do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não poderá ser impedido de fazê-lo, devendo fundamentar a decisão.

Entretanto, anoto que a providência reclamada esbarra em determinados empecilhos que obstem o seu deferimento:

Em primeiro lugar, porque o delito em apreço é doutrinariamente classificado como de perigo abstrato, sem vítima determinada, crime vago, que ofende toda a coletividade, o que torna inviável a aferição de um valor reparatório, ganhando a discussão contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em segundo lugar, porque o legislador ordinário, ao estabelecer a pena para uma conduta criminosa, pode incorporar no preceito secundário, além da sanção corporal, uma sanção pecuniária, a multa, justamente para reparação do dano que a conduta ilícita impõe à sociedade, sendo que a Lei n. 11.343/2006 já previu, além da pena privativa de liberdade, multa bastante rigorosa, de sorte que impor ao réu mais uma sanção pecuniária, a título de reparação de danos à coletividade, equivaleria a agravar a sanção penal ao arrepio dos princípios da legalidade e da reserva legal” (TJSP; Apelação Criminal 1503114-67.2020.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2021; Data de Registro: 10/06/2021).

Caracterizado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, passo à dosagem da pena:

I. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, cumpre fixar a pena-base em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa;

II. Dentre as circunstâncias legais a serem apreciadas, verifica-se a reincidência (autos nº 0000029-16.2016.8.26.0608 – Vara Única de Patrocínio Paulista, pág. 155), a majorar a pena em seis meses de reclusão e em cinquenta dias-multa;

III. Não há causas especiais de aumento, tampouco de diminuição, ressalvando-se a inviabilidade de reconhecimento do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, porque reincidente o agente, conforme anotado no item "II" e, nesse ponto em particular, não há como se acolher o pleito da defesa, pois os requisitos dispostos para a benesse legal referida são de ordem cumulativa e para a reincidência, um de seus componentes, não há distinção para a genérica ou específica, diversamente do que ocorre, por exemplo, com a disciplina legal estabelecida no parágrafo 3º, do artigo 44, do Código Penal, sobre a qual o Superior Tribunal de Justiça já traçou diferenciações entendendo que "A reincidência específica tratada no art. 44, § 3º, do Código Penal somente se aplica quando forem idênticos, e não apenas de mesma espécie, os crimes praticados" (3ª Seção. AREsp 1.716.664-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/08/2021 - Info 706)". Torno definitivo o quantum da pena de cinco anos e seis meses de reclusão e quinhentos e cinquenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a hediondez preservada ao caput da capitulação sob a qual incurso o acusado, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento. Insuficiente o critério objetivo temporal para progressão para o regime semiaberto (artigo 387, parágrafo 2º, do Código Processo Penal), iniciará o cumprimento no regime original.

V. Em relação à pena da multa, fica acolhida a pretensão da defesa da não incidência, conforme previsão contida no artigo 29, caput, da Resolução Nº 425 de 08/10/2021, do Conselho Nacional de Justiça, bem como decisão exarada no Recurso Especial nº 1.785.861-SP, julgado sob a sistemática dos repetitivos (Tema 931), que resultou na fixação da tese de "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade", haja vista a vulnerabilidade do acusado, em situação de morador de rua, e que nada valerá a fixação da pena pecuniária para ressocialização e prevenção do delito.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência condeno JESSE FERREIRA, qualificado nos autos, à pena de cinco anos e seis meses de reclusão (regime fechado), como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "4" de pág. 154).

Em virtude da reincidência, bem como da manutenção de motivos que deram ensejo à prisão cautelar (págs. 94/96), sobretudo agora por estar emoldurada a condenação ao caput, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ou seja, revestida de natureza hedionda, aqui renovada a contemporaneidade da segregação também para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto com o elevado montante da pena e regime prisional imposto a perspectiva de evasão do distrito da culpa se potencializa; portanto, não poderá apelar em liberdade, anotando-se inexistir óbice a essa condicionante (verbete nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra recolhido. Na hipótese de interposição de recurso, extraia-se guia de execução provisória.

Presume-se que a origem do numerário encontrado em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito por ele desenvolvido, especialmente porque não tratou de produzir prova para demonstrar o desenvolvimento de trabalho regular. Diante disso, decreto o perdimento do valor apreendido e depositado às págs. 117, em favor da União.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA